

1502262-73.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... assim que o réu estava praticando o tráfico de drogas. Diante disso passou a fazer algumas filmagens, que já foram apresentadas para a polícia. Na data dos fatos, percebeu novamente o movimento de tráfico de drogas e acionou os Policiais Militares, de serviço, informando sobre o tráfico. Narrou que os policiais chegaram no local, abordaram o acusado e localizaram as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -
cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502262-73.2021.8.26.0530

Controle: 2021/002160

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271535/2021 - DEL.POL.BARRINHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID CARPANEZI DO CARMO

Aos 16 dias do mês de maio de 2022, às 14:30 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS: o Promotor de Justiça, Dr. DANIEL TOSTA DE FREITAS; a Defensora nomeada, Dra. LILIANE DEL GRANDE CLÁUDIO ZARDO (OAB/SP 201054), as testemunhas arroladas em comum Policiais Militares Fábio Roberto Theodoro, Giovani Rodrigo Pereira e Leonardo Saturnino de Souza Silva; AUSENTE: o réu David Carpanezi do Carmo apesar de devidamente intimado as fls. 100. Foi tentado contato com o réu pelo telefone constante aos autos qual seja: (16) 99280-9505 através de mensagens enviadas via aplicativo whatsapp e por ligações telefônicas porém as mensagens não eram recebidas e as ligações caíam na caixa postal. Iniciados os trabalhos, Acerca da ausência do réu David, pelo MM. Juiz foi dito: "Considerando que o réu foi citado as fls. 70 e intimado pessoalmente as fls. 100 deixou de comparecer ao presente ato, DECRETO SUA REVELIA, nos termos do artigo 367, 1ª parte, do Código de Processo Penal." A seguir o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas em comum Policiais Militares Fábio Roberto Theodoro, Giovani Rodrigo Pereira e Leonardo Saturnino de Souza Silva, qualificadas em

videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. E, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e à Dra. Defensora, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA:

"Vistos.

DAVID CARPANEZI DO CARMO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 10h00, na rua Santa Leocárdia nº 398, Vila Recreio, na cidade de Barrinha, comarca de Sertãozinho, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 46 (quarenta e seis) cápsulas de Cocaína pesando 42g (quarenta e dois gramas), droga e substância entorpecente capaz de determinar a dependência física e psíquica.

Segundo a denúncia, alguns dias antes dos fatos Giovanni Rodrigo Pereira, que é policial militar na cidade de São Paulo e passava suas férias no município de Barrinha, havia notado uma intensa movimentação de pessoas no imóvel em frente à residência em que se encontrava, motivo pelo qual passou a monitorar o local e a fazer filmagens. No dia 05 de outubro de 2021, ele voltou a perceber que várias pessoas estavam entrando e saindo do referido imóvel, diante do que acionou a Polícia Militar. Os policiais militares Fábio Roberto Theodoro e Leonardo Saturnino de Souza Silva se deslocaram até o endereço supracitado e surpreenderam David em seu comércio de sucatas. Na ocasião, ele portava uma bolsa presa às pernas, dentro da qual foram encontradas 46 (quarenta e seis) cápsulas tipo eppendorf contendo Cocaína e a quantia de R\$70,00 (setenta reais).

Sendo a denúncia recebida em 03 de novembro de 2021 (fls. 64/65), o réu foi citado (fls. 70) e apresentou defesa prévia (fls. 85/87).

Durante a instrução foram colhidas as declarações de três testemunhas pela acusação. O réu não compareceu na audiência designada, sendo decretada sua revelia. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, por insuficiência de provas, sustentando que a movimentação retratada seria decorrente da comercialização de sucatas. Subsidiariamente, pugnou o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos e o regime aberto.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12), pelo exame químico-toxicológico (fls. 55/57), conclusivo por se tratar de Cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é indubitável.

Os policiais militares Leonardo e Fábio, na fase policial, disseram que receberam denúncia de um colega Policial Militar (de folga), o qual reside em frente ao local dos fatos, dando conta de que o indiciado estaria traficando em seu comércio. Tal denúncia se fez acompanhada de filmagem, a qual demonstrava que o indiciado realmente estava traficando. Diante disto, deslocaram-se para o local apontado e surpreenderam o indiciado, em seu comércio de sucatas, com uma bolsa presa às pernas, na qual, após abordagem, foram localizados 46 (quarenta e seis) eppendorfs contendo Cocaína e a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), sendo dado voz de prisão

em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e apresentado Na Delegacia de Polícia. (fls. 05/06).

Em Juízo, disseram que receberam notícia por parte de outro colega policial militar, que mora defronte ao imóvel do réu, de que o réu estaria traficando, sendo inclusive exibidos vídeos do réu vendendo a droga a terceiros. Após verem os vídeos, foram abordar o réu, que tinha uma pochete, dentro da qual encontraram droga e dinheiro trocado. Informalmente o réu admitiu que estava traficando no local. O policial Leonardo ainda acrescentou que o réu já era conhecido nos meios policiais como traficante. Também disse a testemunha Leonardo acreditar que no local não funciona um comercio de sucata, mas que provavelmente o réu só receba a sucata como pagamento pela droga que vende (v. mídia).

O policial militar Giovanni, na fase policial, disse que é Policial Militar lotado na cidade de São Paulo e estava de férias, à época dos fatos. Relatou que há alguns dias percebeu um aumento no movimento (entra e sai) de pessoas no imóvel em frente à sua casa, o que o levou a monitorar o local, identificando assim que o réu estava praticando o tráfico de drogas. Diante disso passou a fazer algumas filmagens, que já foram apresentadas para a polícia. Na data dos fatos, percebeu novamente o movimento de tráfico de drogas e acionou os Policiais Militares, de serviço, informando sobre o tráfico. Narrou que os policiais chegaram no local, abordaram o acusado e localizaram as drogas e dinheiro apreendido. (fls. 07). Em Juízo, confirmou que ao visitar seus avós, e receber e visualizar movimentação típica do tráfico na residência do réu, de entrada e saída de pessoas, resolveu chamar os policiais. Chegou a fazer filmagens do réu se encontrando e entregando algo para terceiros. Disse ainda não ter conhecimento que na data dos fatos funcione um comercio para venda de sucatas (v. mídia).

O réu, interrogado na fase policial, negou que estivesse traficando drogas e alegou desconhecimento quanto à existência de drogas no local no qual estava (fls. 08). O réu não compareceu na audiência designada, sendo decretada sua revelia (v. mídia). Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais militares, foi o policial Giovanni quem percebeu o ato criminoso do réu e solicitou a presença dos colegas Fábio e Leonardo. O policial Giovanni, de férias no local dos fatos, percebeu uma movimentação atípica ocorrendo na casa que ficava a frente da sua, típica do tráfico de drogas e inclusive fez filmagens desta atividade. Posto isso, foram acionados os policiais Fábio e Leonardo, os quais foram ao local e realizaram abordagem do réu, que estava defronte o imóvel e em sua posse encontraram 46 (quarenta e seis) eppendorfs contendo Cocaína e a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais).

Conforme se infere dos vídeos que podem ser acessados pelo link de fls. 75, de fato há grande movimentação de pessoas na casa do réu, o qual, segundo confirmaram os policiais, ainda estava na posse de significativa quantidade de droga numa pochete, já embalada em porções próprias para venda, assim como dinheiro trocado, tendo inclusive confessado informalmente esta atividade ilícita aos policiais.

No tocante à alegação da Defesa de que a movimentação retratada nos vídeos seria em razão do comercio de sucatas que há no local, observo que não encontra respaldo em qualquer prova dos autos, nem mesmo no interrogatório policial do réu.

O que se tem de concreto, como já dito, e reputo ser suficiente para amparar um decreto condenatório, é que o réu efetivamente trazia consigo numa pochete quantidade significativa de cocaína, muito superior ao que normalmente é encontrado com meros usuários, além de dinheiro trocado, e que diversas pessoas ingressavam em sua residência e mantinham breve contato com o réu, trocando com ele algo, em típica atividade do tráfico de drogas, e ainda a confissão informação do autuado. No mais, a credibilidade dos depoimentos dos policiais ainda vem corroborada pela prova pericial já citada, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos

de que os tivessem a intenção de prejudicar o acusado. Neste sentido:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de milicianos para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

Assim é que não se contesta a validade dos três depoimentos acima delineados, que constituem prova é perfeitamente aceitável.

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Coeso testemunho dos policiais militares – Validade – Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Tráfico caracterizado – Condenação mantida – PENA – redutor no patamar máximo – necessidade – Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto – Recurso parcialmente provido. (TJSP – Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 – Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves – d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP – Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 – Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira – d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA ORAL INCRIMINADORA – A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP – APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 – Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib – d.j. 14.11.2017).

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita

sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14a Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16a Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9a Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200).

Reputo que a acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos, porém tal circunstância atenuante não tem o condão de fazer com que as penas sejam reduzidas aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Neste sentido:

"O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada." (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminosa, reduzo as penas acima indicadas em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010,

DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito "erga omnes", cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante "o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo". Ponderou também que "a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero".

Assim sendo, analisando o caso concreto, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime. Destaco que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu DAVID CARPANEZI DO CARMO, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, por força da decisão proferida pelo STJ no HC nº 596.603 SP (2020/0170612-1), podendo recorrer em liberdade diante da primariedade.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita."

Pela Dra. Defensora foi dito que RECORRE da r. sentença. Pelo Promotor de Justiça foi dito que CONCORDA com a r. sentença. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Intime-se o réu da r. Sentença. Recebo o recurso interposto pela defesa. Aguardo as razões. Após, ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões.

Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Arbitro honorários advocatícios à Defensora nomeada em 70% da tabela OAB/Defensoria, EXPEÇA-SE certidão. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais." Eu, _____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.